

1501023-86.2020.8.26.0621

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUIZ FILIPE SOUZA FONSECA

Comarca: Cachoeira Paulista

Foro: Foro de Cachoeira Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 09/03/2022

... do delito de associação para o tráfico.

Por sua vez, quanto à imputação, aos corréus, do delito de tráfico de entorpecentes (art. 33, Lei 11.343/06), tem-se que merece prosperar.

Isso porque, em relação à destinação da droga para tráfico, esta resta evidenciada pela relevante quantidade de substâncias apreendidas e pela variedade destas (132g de cocaína em 92 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cachoeira Paulista

Foro de Cachoeira Paulista

1ª Vara

Praça Prefeito Prado Filho, s/nº, Cachoeira Paulista-SP - cep 12630-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1501023-86.2020.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501023-86.2020.8.26.0621

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2318946/2020 - DEL.POL.CACHOEIRA PAULISTA, 15342810 - DEL.POL.CACHOEIRA PAULISTA, 842/20/210 - DEL.POL.CACHOEIRA PAULISTA, 2318946 - DEL.POL.CACHOEIRA PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDMAR LINO DOS SANTOS e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUIZ FILIPE SOUZA FONSECA

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou EDMAR LINO DOS SANTOS, vulgo "EDMAR NEGÃO", KAWANY VICTÓRIA INDALÉCIO PEREIRA DOS SANTOS, e SIDNEI JOSE CARDOSO, vulgo "CARECA", porque, no dia 22 de dezembro de 2020, por volta das 09h40, na Rua Henrique Regiane, nº. 62, Pitêu, nesta cidade e comarca de Cachoeira Paulista, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de substâncias entorpecentes.

Consta, ainda, que no dia 22 de dezembro de 2020, por volta das 09 horas e 40 minutos, na Rua Henrique Regiane, nº. 62, Pitêu, nesta cidade e comarca de Cachoeira Paulista, EDMAR LINO DOS SANTOS, vulgo "EDMAR NEGÃO", agindo em concurso

de agentes pela unidade de desígnios visando o fim comum com KAWANY VICTÓRIA INDALÉCIO PEREIRA DOS SANTOS, e SIDNEI JOSE CARDOSO, vulgo "CARECA", guardava e tinha em depósito drogas, para fins de comércio a terceiros, consistentes em três porções de MACONHA, com peso aproximado de 17 gramas, 92 pinos de eppendorfs contendo COCAÍNA, com peso aproximado de 132 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, também, que, nas mesmas condições de tempo e lugar acima consignadas, EDMAR LINO DOS SANTOS, vulgo "EDMAR NEGÃO", possuía e guardava, ainda que gratuitamente, maquinário, aparelho ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, outrossim, que, nas mesmas condições de tempo e local acima consignadas, EDMAR LINO DOS SANTOS, vulgo "EDMAR NEGÃO", possuía, no interior de sua residência, arma de fogo de uso permitido e duas munições, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de acordo com auto de exibição e apreensão de fls. 32/34 e laudo pericial que será oportunamente juntado aos autos.

Consta, também, que no dia 22 de dezembro de 2020, por volta das 09h40 horas, Rua Lagoinha, na casa 325, Bairro do CDHU, nesta cidade e comarca de Cachoeira Paulista, SIDNEI JOSE CARDOSO, vulgo "CARECA", agindo em concurso de agentes pela unidade de desígnios visando o fim comum com KAWANY VICTÓRIA INDALÉCIO PEREIRA DOS SANTOS, e EDMAR LINO DOS SANTOS, vulgo "EDMAR NEGÃO", guardava e tinha em depósito drogas, para fins de comércio a terceiros, consistente em 1.269 pinos de eppendorfs contendo COCAÍNA, com peso aproximado de 1.675 g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, ainda, que, nas mesmas condições de tempo e lugar acima consignadas, SIDNEI JOSE CARDOSO, vulgo "CARECA", possuía e guardava, ainda que gratuitamente, maquinário, aparelho ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, também, que, no dia 22 de dezembro de 2020, por volta das 09h40, Rua Orris Benedito Barbosa, nº. 210, apartamento 503, Pitéu, nesta cidade e comarca de Cachoeira Paulista, KAWANY VICTÓRIA INDALÉCIO PEREIRA DOS SANTOS, agindo em concurso de agentes pela unidade de desígnios visando o fim comum com SIDNEI JOSE CARDOSO, vulgo "CARECA", e EDMAR LINO DOS SANTOS, vulgo "EDMAR NEGÃO", guardava e tinha em depósito drogas, para fins de comércio a terceiros, consistente em cinco tabletes de MACONHA prensadas, com peso aproximado de 359 gramas; 102 porções de MACONHA, com peso aproximado de 316 gramas; 2.578 pinos de eppendorfs contendo COCAÍNA, com peso bruto aproximado de 3.540 g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, por fim, que, nas mesmas condições de tempo e lugar acima consignadas, KAWANY VICTÓRIA INDALÉCIO PEREIRA DOS SANTOS, possuía e guardava, ainda que gratuitamente, maquinário, aparelho ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ante o exposto, requer o Ministério Público seja os réus condenados: EDMAR LINO DOS SANTOS, vulgo "EDMAR NEGÃO", como incurso nos artigos 33, caput, artigo 34, caput e artigo 35, caput todos da Lei n.º 11.343/06 e artigo 12, caput da Lei 10.826, todos na forma do artigo 69 do Código Penal; KAWANY VICTÓRIA INDALÉCIO PEREIRA DOS SANTOS, como incurso nos artigos 33, caput, artigo 34, caput e artigo 35, caput, todos da Lei n.º 11.343/06 na forma do artigo 69 do Código Penal; SIDNEI JOSE CARDOSO, vulgo "CARECA", qualificado a fls. 22 e 139/140, como incurso nos artigos 33, caput, artigo 34, caput e artigo 35, caput, todos da Lei n.º 11.343/06 na forma do artigo 69 do Código Penal.

Decisão convertendo a prisão em flagrante em preventiva de SIDNEI JOSÉ CARDOSO E EDMAR LINO DOS SANTOS, e decretando a prisão preventiva de KAWANY VICTÓRIA INDALÉCIO PEREIRA DOS SANTOS. (fls.212/220).

Notificados, os réus apresentaram defesa prévia (fls.413/419; 469/471; 581/583).

A denúncia foi recebida em 10 de agosto de 2021(fl. 590/592).

Em audiência de instrução e julgamento (fls. 645), foram inquiridas as testemunhas,

e ao final, interrogados os réus, tudo por meio audiovisual.

Em alegações finais (fls.678/684), apresentada por meio de memoriais, o Ministério Público pugnou pela parcial procedência da ação penal.

A defesa do réu Edmar (fls.687/694) postulou pela absolvição do réu por falta de provas.

Já a defesa do réu Sidnei (fls.695/704) requereu que na hipótese de condenação do pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, que seja fixada a pena no mínimo legal; o reconhecimento da confissão espontânea; aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06; pela absolvição quanto ao delito do art.35, caput, da lei 11.343/06; a restituição da quantia de R\$ 4.000 (quatro mil reais); e que seja fixada a pena em regime aberto, bem como a conversão em pena restritivas de direitos.

Por sua vez, a defesa da ré Kawany (fls.710/718) pugnou pela absolvição da ré, e em caso de eventual condenação que seja aplicada a pena no mínimo legal, sendo afastado o concurso de pessoas e o regime inicial aberto.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.

Não havendo preliminares a serem enfrentadas, passo, desde logo, ao exame do mérito.

A condenação penal depende da conjunção de dois elementos, quais sejam: prova de materialidade do crime e de sua autoria.

Visando à comprovação da materialidade, constam nos autos o auto de exibição e apreensão (fls. 38/46), pelo laudo de constatação provisória (fls. 64/67), pelo contrato de aluguel (fls. 149/152), pelas fotografias dos locais dos fatos (fls. 252/264), pelos laudos dos objetos (fls. 314/321, 322/324, 329/333), pelo laudo da arma de fogo (fls. 325/328), pelo laudo do local dos fatos (fls. 334/337).

Ademais, a prova oral foi colhida no seguinte sentido:

A testemunha Marco Antônio do Amaral, policial militar, declarou que, na data dos fatos, em apoio ao cumprimento do mandado de busca, dirigiu-se até a casa de EDMAR. Ao notar a presença policial, o acusado tentou empreender fuga e dispensou duas sacolas em cima do telhado da casa vizinha. Ao ser abordado, EDMAR trazia no interior de sua boca uma munição de arma de fogo. Nas sacolas dispensadas, continha aproximadamente noventa pinos de cocaína. No interior da residência, foi apreendido um revólver, calibre .38. Foram dar apoio na busca na residência de Kawany e, no local, foram localizados mais de dois mil eppendorfs contendo cocaína, além de muitos eppendorfs vazios e 102 buchas de maconha e aproximadamente 14 ou 15 tabletes de maconha prensada. Tinham conhecimento de que o local era utilizado para armazenar drogas de EDMAR e se tratava da residência da ré. Consignou que já abordaram Kawany e Edmar juntos. Disse que Sidnei relatou na delegacia que a droga armazenada por ele era de Edmar. Informou que havia informações pretéritas que a casa de Kawany era ponto de venda de drogas.

A testemunha João Guilherme Ribeiro, policial militar, apresentou a mesma versão do colega de farda. Acrescentou que já havia notícias anteriores sobre o envolvimento de Edmar no tráfico de entorpecentes.

A testemunha Luis César Franklin, agente policial, declarou que o setor de investigações de Cachoeira Paulista recebeu diversas informações a respeito de um indivíduo conhecido como "Edmar Negão", o qual, vindo da cidade de Lorena, iniciou a trajetória no tráfico nesta cidade. Passaram a colher informações e observá-lo, conseguindo obter seu endereço. As informações davam conta de que ele não armazenava drogas em sua casa, apenas dinheiro e armas de fogo, contando com comparsas que guardavam grandes quantidades de entorpecentes, para redistribuir para traficantes menores. Durante as investigações, chegaram à residência de Kawany e "Careca". Então, representaram pela expedição de mandado de busca e apreensão. Com relação à busca realizada na casa de Edmar, corroborou a versão dos policiais militares. Acrescentou que, posteriormente, dirigiu-se até a casa de "Careca" e se depararam com Sidnei no local. Em busca foi localizada grande quantidade de drogas, já preparada para a venda, aproximadamente 1300 pinos cheios, além de material para preparo. Por fim, dirigiram-se até a residência de Kawany e localizaram mais drogas, aproximadamente 2500 pinos e maconha. Todo o material foi apreendido. A

autoridade policial conseguiu com o proprietário do apartamento o contrato de locação daquela residência, o que possibilitou na sua qualificação.

A testemunha, Roberto da Silva Oliveira, policial civil, confirmou a versão apresentada pelos demais agentes públicos.

A testemunha Carlos Jaime da Silva Júnior não presenciou os fatos. Limitou-se a dizer que foi professor de Kawany.

Interrogado, EDMAR LINO DOS SANTOS confirmou que as drogas e a arma foram localizadas em sua residência. Disse que a droga iria ser utilizada nas festas de fim de ano, junto com seus amigos.

Por sua vez, SIDNEI JOSE CARDOSO confirmou que armazenava as drogas, mas não para EDMAR.

Por fim, a acusada KAWANY VICTÓRIA INDALÉCIO PEREIRA DOS SANTOS disse que conheceu a filha de EDMAR e começou a se envolver com ela. Alugou o apartamento para ficar perto dela, mas acabaram terminando. Então, foi para a casa de sua tia. Soube posteriormente que EDMAR vendia drogas. Confirmou que foi abordada acompanhada de EDMAR quando estavam indo para uma festa. Pediu à filha de EDMAR que entregasse a chave ao proprietário do apartamento.

Após a exposição da prova oral, passo a analisar, individualmente, os tipos penais que são imputados pelo Ministério Público aos réus.

Inicialmente, no que tange à imputação do delito de petrechos para o tráfico (art. 34 da Lei 11.343/2006), entendo que a materialidade não restou demonstrada.

Isso porque, segundo a denúncia, os acusados guardavam e possuíam 79 pinos vazios de eppendorfs na cor verde (fls.43/46); dois pacotes vazios de eppendorfs; dois rolos de saco plástico transparente, utilizado para a embalagem de drogas; 59 pinos vazios de eppendorfs na cor verde (fls.38/39), embalagens tipo eppendorff; sacolés e um pacote de bicarbonato de sódio (fls.40/42).

Sucedendo que a posse de tais utensílios não encontra aptidão para tipificar o delito em epígrafe, previsto no art. 34 da Lei 11.343/2006, abaixo transcrito:

Art. 34. Fabricar, adquirir, utilizar, transportar, oferecer, vender, distribuir, entregar a qualquer título, possuir, guardar ou fornecer, ainda que gratuitamente, maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Isso porque, ainda que as circunstâncias da apreensão demonstrem que os objetos apreendidos se relacionam à prática do tráfico de drogas, não é possível afirmar que esses se destinavam especificamente à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, conforme especial fim de agir exigido pelo tipo penal em comento.

Afinal, ainda que objetos como a sacolés, bicarbonato de sódio e os pinos eppendorff sejam utilizados comumente para embalagem, pesagem e incremento de drogas, estas condutas não se inserem ou confundem com os conceitos de fabricar, preparar, produzir ou transformar drogas, os quais devem ter seu significado extraído a partir de uma interpretação estrita, como corolário do princípio da legalidade.

Nessa senda, como leciona a doutrina de Renato Brasileiro de Lima, fabricação consiste na "produção em larga escala"; preparação significa a "obtenção de algo por meio da composição de elementos"; produção é "manufaturar ou fazer surgir em menor escala" e, por derradeiro, transformação traduz-se na "alteração da composição original" (LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação criminal especial comentada: volume único. 7 ed. Salvador: Juspodivm, 2019, p. 1216.).

Assim, pelo que consta nos autos, os utensílios apreendidos supostamente com os réus se destinavam não à preparação, fabricação, produção ou transformação das drogas conforme conceitos acima explanados -, mas à distribuição e embalagem dos entorpecentes já previamente preparados/produzidos ou fabricados, para a venda, finalidade esta que não se amolda aos limites do tipo penal.

Este, aliás, o entendimento da doutrina acerca do tema:

De fato, as balanças apenas pesam a droga e os sacos plásticos se prestam unicamente a acondicioná-la. Logo, embora evidentemente os petrechos sirvam para a prática do tráfico de drogas, tais objetos não podem ser equiparados a instrumentos

aptos a fabricar (produzir em larga escala), preparar (obter produto por meio da composição de elementos), produzir (manufaturar ou fazer surgir em menor escala) ou transformar (alterar a composição primitiva) drogas" (MASSOM, Cleber; MARÇAL, Vinícius. Lei de Drogas: aspectos penais e processuais. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2019. (fls.92/93) destaquei.

No mesmo sentido, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça e do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em casos análogos: (grifos nossos) RECURSO ESPECIAL Nº 1.511.301 - AC (2015/0023950-6) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE RECORRIDO : EDNILSON PEREIRA DE SOUZA ADVOGADO : ULISSESD'ÁVILA MODESTO E OUTRO (S) - AC000133 DECISÃO "[...] A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência desta Corte e não merece reparo. Conforme decidido, a posse de balança de precisão e sacolas plásticas, por si só, não permitem a fabricação, o preparo, a produção ou transformação das drogas, mas sim a pesagem, acondicionamento e a embalagem dos entorpecentes, logo a absolvição deve ser mantida, como posto pelas instâncias ordinárias, em razão da atipicidade da conduta." [...] (STJ-REsp:1511301AC2015/0023950-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: DJ 12/11/2018).

MATERIALIDADE auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo comprovação que os materiais apreendidos são drogas (maconha, cocaína e crack).AUTORIA depoimento policial que indica a apreensão de droga em poder dos réus e do menor validade depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado inoportunidade no caso em tela. TRÁFICO destinação a terceiros quantidade e variedade, incomum com a figura do usuário; apreensão de dinheiro, balança de precisão e material para embalagem de rigor a condenação dos réus provimento ao recurso ministerial. CAUSA DE AUMENTO prática do delito que envolveu adolescente causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/06 configurada. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ausência de prova de estabilidade e permanência de rigor a absolvição improvimento ao apelo ministerial. PETRECHOS DE FABRICAÇÃO DE ENTORPECENTES insumo químico utilizado como precursor para fabricação e síntese de entorpecentes apreensão de facão, tesoura, balança de precisão e embalagens vazias petrechos e insumo que não integra a descrição do tipo atipicidade de rigor a absolvição improvimento para este fim. [...] (TJ-SP- APR:15017475920178260536 SP 1501747-59.2017.8.26.0536, Relator:Lauro Mens de Mello, Data de Julgamento: 06/10/2020, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 06/10/2020)

PRELIMINAR ILICITUDE DA PROVA DECORRENTE DAINVASÃO DE DOMICÍLIO caso em que se adentrou a residência em situação de flagrante delito uma das hipóteses garantida pela Constituição Federal ocultação de drogas no interior da casa delito permanente constante o estado de flagrante busca e apreensão amparada em fundadas suspeitas, já que os policiais puderam confirmar denúncias anônimas ao constatarem o réu que reunia as características físicas declinadas saindo de local também indicado na denúncia como sendo o imóvel onde eram guardadas as armas e drogas inexistência de ilegalidade lícitude da diligência realizada lícitude das provas colhidas em face do flagrante preliminar afastada. PETRECHOS DE FABRICAÇÃO DE ENTORPECENTES balança e embalagens vazias não integra a descrição do tipo atipicidade de rigor a absolvição - provimento para este fim. TRÁFICO MATERIALIDADE - auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo comprovação que o material apreendido é droga. [...]. (TJ-SP 00355998820168260050 SP0035599-88.2016.8.26.0050, Relator: Lauro Mens de Mello, Data de Julgamento: 10/05/2018, 12ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 18/05/2018). Por todo o exposto, em relação ao delito do art. 34 da Lei 11.343/2006, os réus devem ser absolvidos, com fulcro no art.386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ato contínuo, no que concerne à imputação, aos corréus, do delito de associação para o tráfico (art. 35, Lei 11.343/06), tem-se que esta também não merece prosperar. Isso porque, para que se verifique a tipicidade do delito em questão é necessária a demonstração de algum grau de estabilidade e permanência na associação dos agentes.

O crime do art. 35 da Lei 11.343/06 "configura-se com o animus associativo, isto é, um ajuste prévio, no sentido de formação de um vínculo associativo de fato, uma verdade, em que a vontade de se associar sobrepaire, mas coexista com a vontade necessária à prática do crime visado" (TJSP, Ap. Crim, 210. 425-3/7, 4º Câmara, rel Des. Bittencourt Rodrigues, RT745/539).

Na hipótese em deslinde, contudo, entendo que não há provas suficientes para comprovação, por elementos objetivos concretos, qualquer nível de apuração ou sequer a existência do vínculo existente entre os réus na associação para fins de praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Nesse sentido, extrai-se dos autos que pairam apenas indícios acerca da suposta associação entre os réus, sem qualquer indicativo de estabilidade, divisão de tarefas ou hierarquia. A acusação se pauta, principalmente, em uma diligência da Polícia Militar, na qual foram encontrados nas residências dos réus porções de drogas e objetos supostamente destinados a preparação destas. Além disso, os réus negam que se conhecem, tendo apenas o relato do policial militar atestando que já abordou Edmar e Kawany juntos.

Estes fatos são indícios circunstanciais que não satisfazem o elevado standard probatório que é exigido para justificar uma condenação criminal, na medida em que também não demonstram, de forma concreta, qualquer estabilidade ou permanência em uma associação hierarquicamente dividida para a prática do tráfico de drogas. Para a comprovação do crime de associação para o tráfico ilícito de drogas seriam necessários elementos concretos de prova no sentido de existência do referido vínculo associativo entre os agentes, extraídos possivelmente a partir de interceptações telefônicas, pedidos de busca e apreensão, campanhas em datas anteriores, apreensão de eventual documentação ligada ao tráfico ou de drogas pertencentes aos acusados, não bastando, desse modo, informações genéricas e anônimas dando conta de que os mesmos agentes vinham praticando a mercancia ilícita.

Nesse sentido, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça e do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: (grifos nossos)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA ASSOCIAÇÃO. PLURALIDADE DE AGENTES. INEXISTÊNCIA. LOCALIDADE DOMINADA POR FACÇÃO CRIMINOSA. PRESUNÇÃO DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NO GRUPO CRIMINOSO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DA ASSOCIAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. [...]. 1. Firmou-se neste Superior Tribunal de Justiça entendimento no sentido de que indispensável, para a configuração do crime de associação para o tráfico, a evidência do vínculo estável e permanente do acusado com outros indivíduos. 2. Ainda que seja de conhecimento o domínio da localidade por facção criminosa e a posse de arma e munição de uso restrito denotem envolvimento com atividades criminosas, não há na denúncia, na sentença ou no acórdão qualquer apontamento de fato concreto a caracterizar o vínculo de agentes, requisito necessário para a configuração do delito de associação para o tráfico, não tendo sido sequer indicado quem seriam os outros que com ele estariam associados, de modo que, ausente o requisito atinente à pluralidade de agentes, imperiosa é a absolvição. 3[...] (STJ - HC: 474965 RJ 2018/0275958-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2019).

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ART. 35 DA LEI N. 11.343/2005. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. CONCESSÃO DA ORDEM. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é imprescindível a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa (HC n. 270.837/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTICRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 30/03/2015). 2. Ordem concedida para absolver o paciente da prática do delito do art. 35 da Lei n. 11.343/06. (STJ - HC: 393231 RJ 2017/0064014-6, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 21/11/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2017).

Por todo o exposto, a absolvição dos acusados é medida que se impõe, na formado

art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal, eis que não restou provada a existência do delito de associação para o tráfico.

Por sua vez, quanto à imputação, aos corréus, do delito de tráfico de entorpecentes (art. 33, Lei 11.343/06), tem-se que merece prosperar.

Isso porque, em relação à destinação da droga para tráfico, esta resta evidenciada pela relevante quantidade de substâncias apreendidas e pela variedade destas (132g de cocaína em 92 pinos de eppendorfs; 17g de maconha em três porções; 1.675g de cocaína em 1.269 pinos de eppendorfs; 316 g de maconha em 102 porções; 359 g de maconha prensadas em 05 tabletes; 3.540g de Cocaína em 2.578 pinos de eppendorfs), bem como a de outros instrumentos destinados comumente ao tráfico (pinos vazios de eppendorfs; sacolés ; um pacote de bicarbonato de sódio), além de uma significativa quantia em dinheiro - não deixando dúvidas de que a destinação das drogas era para realmente o comércio ilegal.

No caso em concreto, os entorpecentes foram encontrados nas residências dos respectivos réus, resultando no auto de prisão em flagrante (fls.09/10) sendo confirmada, em interrogatório, pelos réus Edmar e Sidnei, ainda, a versão apresentada pela ré Kawany resta isolada nos autos, sem capacidade de infirmar o harmônico relato policial corroborado pelo restante do conjunto probatório.

Além disso, sem capacidade de infirmar o harmônico relato policial corroborado pelo restante do conjunto probatório. Os policiais militares prestaram depoimento coerente a respeito da apreensão da droga, no sentido de que o acusado Edmar já era conhecido nos meios policiais, e por meio de investigações chegou à residência de Kawany e Sidnei. Assim, por meio de mandado de busca e apreensão expedido, foram encontrados os entorpecentes já descritos nas respectivas residências.

Neste ponto, imperioso observar que a narrativa acusatória encontra lastro no depoimento dos Policiais Militares, tanto na fase inquisitorial como em Juízo. Quanto a isso, é certo que os depoimentos dos policiais, quando coesos e harmônicos,, constituem elementos probatórios aptos a justificar a condenação criminal.

Nesse sentido:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC nº 74.608-0-SP, Rel. Min.Celso de Mello).

"O depoimento testemunhal do policial que atuou na ocasião do flagrante possui eficácia probatória, sendo certo que não se pode descartá-lo e deixar de considerá-lo como suporte da condenação, pelo simples fato de emanar de agentes estatais incumbidos da repressão penal" (TJSP, Des. Walter de Almeida Guilherme, RT 816:548) Nesse sentido, aliás, a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça Do Estado de SãoPaulo e C. Superior Tribunal De Justiça, conforme ementa transcrita abaixo (com grifos nossos):

Tráfico de entorpecentes. Materialidade e autoria comprovadas. Validade dos depoimentos dos policiais corroborados pelas provas diretas e indiciárias. Destinação dos entorpecentes à entrega onerosa ao consumo de terceiros extraída das circunstâncias do fato. Afastamento da desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06. Condenação bem decretada. Caracterização da causa especial de aumento de pena relativa ao envolvimento de adolescente. Base mínima. Impossibilidade de atenuação pela menoridade relativa. Sum. 231 do STJ. Redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06que beneficiou o apelante. Descabimento da substituição da carcerária por restritivas de direitos e do "sursis" ante a insuficiência dessas medidas. Adequação do regime prisional fechado. Recurso desprovido. (TJ-SP - APL:00020984720158260352 SP 0002098-47.2015.8.26.0352, Relator: Marcos Correa, Data de Julgamento: 15/09/2016, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/09/2016)

Assim, reputo comprovado que as drogas encontradas eram sim do réu, a grande quantidade de entorpecentes apreendida e, ainda, às circunstâncias da apreensão evidenciam a finalidade mercantil.

Nesse sentido, tendo em vista a grande quantidade de entorpecentes apreendidos, evidencia que os acusados se dedicavam a atividades criminosas.

Saliento que o quadro sob análise é muito diferente daquele praticado por pequenos traficantes que são encontrados com pequenas porções de drogas, longe de atingir a referida medição. Nesse sentido, os seguintes julgados do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: (grifos nossos)

"Apelação. Tráfico ilícito de entorpecentes. Recurso buscando a absolvição por insuficiência probatória, desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas, aplicação do redutor pelo tráfico "privilegiado" em patamar máximo e imposição de regime semiaberto. Processo penal. Prova. Tráfico ilícito de entorpecentes. Testemunhos dando conta de que o apelante era o único morador da casa onde encontrados os entorpecentes. Ausência de indícios de que as testemunhas visem incriminá-lo falsamente. Apreensão de grande quantidade e variedade de drogas (99g de maconha em 2 porções, 11,4 g de cocaína em 40 porções, 12,7g de "crack" em 57 pedras, mais 28,9g em 4 porções médias), além de petrechos destinados embalo e razoável quantia em dinheiro. Destinação ao comércio devidamente atestada. Desclassificação impossível. Penal. Dosimetria. Tráfico de entorpecentes. Redutor que nem mesmo se mostrava cabível, diante da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos. Circunstâncias que, ao menos, justificaram redução menor na pena. Aplicação no máximo de 2/3 não se mostra cabível. Penal. Tráfico de entorpecentes. Fixação de regime inicial fechado. Necessidade. Observância da Lei de Crimes Hediondos. Aplicação de penas alternativas e concessão de sursis a traficante. Impossibilidade. Ausência de inconstitucionalidade no artigo 44, caput, da Lei de Tóxicos. Recurso desprovido" (9ª Câmara Criminal Extraordinária, Ap. 0002687-73.2014.8.26.0352, Des. Rel. Souza Nery, j. 19.05.2017).

"Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Apreensão de 4 kg de cocaína. Sentença condenatória. Defesa requer a redução da reprimenda, o reconhecimento da figura privilegiada e a atenuação do regime prisional. Materialidade e autoria comprovadas. Traficância configurada. Réu preso em flagrante com elevada quantidade de entorpecente e petrechos para refinaria. Majoração da pena base em metade fundamentada na quantidade e qualidade de entorpecentes deve prevalecer. Confissão parcial não utilizada como razão de decidir, não sendo obrigatória a sua aplicação. Impossibilidade de aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Tóxicos devido à quantidade de entorpecentes apreendidos, compatível com traficante de grande porte. Regime inicial fechado deve prevalecer, pela gravidade e hediondez do crime. Impossibilidade de substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos vedação legal. Recurso não provido" (8ª Câmara de Direito Criminal, Ap. 0036553-10.2014.8.26.0114, Des. Rel. Carlos Monnerat, j. 18.02.2016)

Por fim, no que concerne a imputação prevista no art. 12 da lei nº 10.826/03, em relação ao réu Edmar, tem-se que merece prosperar.

Isto porque, através do auto de exibição e apreensão (fls. 40/42), somada com a confissão do réu e relato dos policiais que realizaram a busca e apreensão na residência do réu, confirmaram a existência da materialidade e autoria do delito em questão.

Nesse sentido, foi encontrada na residência do réu um revólver da marca TAURUS, calibre 38, de uso permitido.

Por conseguinte, comprovadas as existências e autorias dos delitos de tráfico de drogas (réus Edmar Lino dos Santos, Kawany Victória Indalécio Pereira dos Santos e Sidnei Jose Cardoso) de posse de arma de fogo de uso permitido (corréu Edmar Lino dos Santos), a deflagração da responsabilidade penal é medida que se impõe, com o que passo, agora, à fase da individualização da pena de forma separada.

Da dosimetria da pena da ré Kawany Victória Indalécio Pereira dos Santos

Do delito do art. 33 da Lei nº 11.343/06

Na primeira fase, atendendo às diretrizes do art. 59, "caput", do Código Penal c.c.com o artigo 42 da Lei nº 11.343/06, a quantidade exacerbada de drogas (notadamente quando contrastada com as apreensões regulares nesta comarca) e a

natureza dos entorpecentes (apreensão de cocaína com maior potencial danoso aos usuários), justificam maior exasperação, razão pela qual elevo a pena base em ¼. As demais circunstâncias do tipo penal ou são inerentes ao tipo ou não contam com elementos nos autos que justifiquem a sua valoração negativa. Assim, fixo a pena base em 06 (seis) anos e 03(três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria não vislumbro circunstâncias agravantes e atenuantes a serem consideradas, razão pela qual mantenho apenas intermediária em 06 (seis) anos e 03(três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa. Na terceira fase da dosimetria, não havendo outras causas de diminuição ou aumento de pena, fixo a pena definitiva em 06 (seis) anos e 03(três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

No que toca ao regime inicial de cumprimento de pena, com base no art.33, § 2º, "b", do CP, fixo o regime inicial de pena como o semiaberto.

Em relação ao valor unitário da multa, a teor do art. 49, § 1º, do Código Penal, entendo pela aplicação de 1/30 do salário-mínimo, pois não há dados sobre a situação econômica da ré.

Por derradeiro, pela quantidade de pena privativa de liberdade imposta, deixo de operar a substituição por restritiva de direitos (art. 44, inciso I, do Código Penal), ou a suspensão condicional da pena, a teor do art. 77, caput, do Código Penal.

Da dosimetria da pena do réu Sidnei Jose Cardoso.

Do delito do art.33 da Lei nº 11.343/06

Na primeira fase, atendendo às diretrizes do art. 59, "caput", do Código Penal c.c.com o artigo 42 da Lei n.º 11.343/06, a quantidade exacerbada de drogas (notadamente quando contrastada com as apreensões regulares nesta comarca) e a natureza dos entorpecentes (apreensão de cocaína com maior potencial danoso aos usuários), justificam maior exasperação, Além disso, o réu apresenta maus antecedentes (fls.658/660), razão pela qual fixo a pena base em 07 (sete) anos, 03(três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria há de se considerar a atenuante da confissão espontânea (art.65, III, alínea "d" do CP), razão pela qual minoro apenas intermediária em 1/8, fixando-a em 06 anos (seis), 04 (quatro) meses e 16 (dezesesseis) dias de reclusão, e 637 (seiscentos e trinta e sete) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, como já salientado, não sendo caso de aplicação da causa de aumento de pena do art.40, VI, da Lei nº 11.343/06, e não havendo outras causas de diminuição ou aumento de pena, fixo a pena definitiva em 06 anos (seis), 04 (quatro) meses e 16 (dezesesseis) dias de reclusão, e 637 (seiscentos e trinta e sete) dias-multa.

No que toca ao regime inicial de cumprimento de pena, com base no art.33, § 2º, "b", do CP, fixo o regime inicial de pena como o fechado, tendo em vista a multiplicidade e gravidade de circunstâncias judiciais negativas e o quantum de pena aplicado.

Em relação ao valor unitário da multa, a teor do art. 49, § 1º, do Código Penal, entendo pela aplicação de 1/30 do salário-mínimo, pois não há dados sobre a situação econômica da ré.

Por derradeiro, pela quantidade de pena privativa de liberdade imposta, deixo de operar a substituição por restritiva de direitos (art. 44, inciso I, do Código Penal), ou a suspensão condicional da pena, a teor do art. 77, caput, do Código Penal.

Da dosimetria da pena do réu Edmar Lino dos Santos

Do delito do art.33 da Lei nº 11.343/06

Na primeira fase, atendendo às diretrizes do art. 59, "caput", do Código Penal c.c.com o artigo 42 da Lei n.º 11.343/06, a quantidade exacerbada de drogas (notadamente quando contrastada com as apreensões regulares nesta comarca) e a natureza dos entorpecentes (apreensão de cocaína com maior potencial danoso aos

usuários), justificam maior exasperação. Além disso, o réu apresenta maus antecedentes (fls.663/668), razão pela qual fixo a pena base em 07 (sete) anos, 03(três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, há de se considerar a agravante da reincidência (art.61, I, do CP) e a atenuante da confissão espontânea (art.65, III, alínea "d" do CP), as quais serão compensadas, conforme entendimento sedimentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual mantenho a pena intermediária em 07 (sete) anos, 03(três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, e não havendo causas de diminuição ou aumento de pena, fixo a pena definitiva em 07 (sete) anos, 03(três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

Do delito do art. 12 da lei nº 10.826/03

Na primeira fase da dosimetria verifico a presença de maus antecedentes (fls.663/668), razão pela qual majoro a pena base em 1/6. Os demais elementos a serem considerados são inerentes ao tipo penal ou normais à espécie, fixo a pena base em 01 (um) ano, 02 (dois) meses de detenção e 11(onze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, há de se considerar a agravante da reincidência (art.61, I, do CP) e a atenuante da confissão espontânea (art.65, III, alínea "d" do CP), as quais serão compensadas, conforme entendimento sedimentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual mantenho a pena intermediária em 01 (um) ano, 02 (dois) meses de detenção e 11(onze) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, ausentes causas de aumento ou de diminuição, fixo a pena definitiva em 01 (um) ano, 02 (dois) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa. Além disso, há concurso material entre os delitos. Com efeito, a teor do disposto no artigo 69 do Código Penal, as penas devem ser somadas, totalizando 07 (sete) anos, 03(três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, 01 (um) ano, 02 (dois) meses de detenção e 11(onze) dias-multa e e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa. Diante do exposto, estabeleço a pena definitiva em 07 (sete) anos, 03(três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 01 (um) ano, 02 (dois) meses de detenção e 740 (setecentos e quarenta) dias multa.

Tendo em vista a quantidade de reprimenda imposta e o acusado ser reincidente, atribuo como regime inicial de cumprimento de pena o fechado para a pena de reclusão e semiaberto para a detenção, de acordo com o disposto no art. 33, § 2º, "a" do Código Penal.

Em relação ao valor unitário da multa, a teor do art. 49, § 1º, do CP, entendo pela aplicação de 1/30 do salário-mínimo, pois não há dados sobre a situação econômica da ré.

Por derradeiro, também pela quantidade de pena privativa de liberdade imposta, deixo de operar a substituição por restritiva de direitos (art. 44, inciso I, do Código Penal), ou a suspensão condicional da pena, a teor do art. 77, caput, do Código Penal.

Deixo de computar o tempo de prisão provisória, nos termos do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, pois ausentes informações seguras sobre a satisfação dos demais requisitos para a detração da pena ou eventual progressão de regime, o que reforça a tese de que a avaliação dos requisitos indispensáveis à concessão desses benefícios somente é possível pelo Juízo da Execução da Pena.

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para CONDENAR:

A ré KAWANY VICTÓRIA INDALÉCIO PEREIRA DOS SANTOS como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos;

O réu SIDNEI JOSE CARDOSO, vulgo "CARECA", como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, à pena de 06 anos (seis), 04 (quatro) meses e 16 (dezesesseis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 637 (seiscentos e trinta e sete) dias-multa., no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos;

O réu EDMAR LINO DOS SANTOS, vulgo "EDMAR NEGÃO", como incurso nos artigos 33,

caput, da Lei n.º 11.343/06 e art.12 da Lei nº 10.826/03, às penas de 07 (sete) anos, 03(três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, inicialmente em regime fechado, e 01 (um) ano, 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e 740 (setecentos e quarenta) dias multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos;
ABSOLVO os réus dos delitos previstos nos artigos 34 e 35 da Lei nº 11.343/06, com fundamento no artigo 386, VII e II do CPP;

Decido por manter a prisão preventiva do réu preso, pois nos termos do art. 312 do CPP, enfatiza a necessidade de garantia da ordem pública, entendida essa como módulo de proteção à possibilidade de reiteração criminosa. Também, diante da evidente prova da ocorrência do delito, tendo em vista a materialidade e autoria comprovadas. Desse modo, não concedo o direito de recorrer desta sentença em liberdade, nos termos do art.387, § 1º, do Código de Processo Penal.

EXPEÇA-SE guia provisória, com urgência.

Transitada em julgado a presente sentença:

- a) Expeça-se a guia definitiva, encaminhando-se ao juízo das execuções criminais;
- b) Intime-se os acusados para pagamento dos dias-multa, no prazo de 10 dias;
- c) Oficie-se o Instituto de Identificação do Estado de São Paulo, bem como ao TRE, para os fins do art. 15, III, da CF;
- d) Anote-se a condenação definitiva no Sistema Informativo Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012, da E. Corregedoria Geral de Justiça (art. 372 das NSCGJ).

Condeno, ainda, os réus ao pagamento das custas processuais na forma da lei.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cachoeira Paulista, 08 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA